

מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/74/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין אסתי שחל

בעניין

1. דורה בר לב
2. אהרון ירושלמי
3. דניאל ירושלמי
4. גלעד סולניק
5. מרין סולניק
6. ערן ונגר
7. רויטל זלצר
8. ביטר יוסף
9. גילה בלה

באמצעות ב"כ עו"ד גיא בטאט
יגאל אלון 65, תל אביב-יפו

תובעים

נגד

1. שיזף עפרה
2. כהן אמיר

ע"י ב"כ עו"ד מירה וולף
רח' תא' באייר 18, תל אביב 6209309

נתבעים

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "**חוק החיזוק**").
2. התובעים הם בעלים של 5 דירות מתוך 6 דירות בבית המשותף אשר נמצא ברחוב השושנים 6, הרצליה הידוע כגוש 6529 חלקה 138 (להלן: "**הבית**").
3. הנתבעים 1 ו- 2 הם בעלים של דירה בבית.
4. במסגרת התביעה, עותרים התובעים בהתאם לחוק החיזוק לאשר להם, חרף התנגדות הנתבעים, ביצוע עבודות ברכוש המשותף, הכוללות עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה לפי תכנית המתאר הארצית 38 (להלן: "**תמ"א 38**") בהתאם להסכם מיום 4.3.2015, שנחתם בינם ובין היזם, י.לי - דה השקעות בע"מ ח.פ. 513092916 (להלן: "**היזם**"), לביצוע עבודות אלה (להלן: "**ההסכם**"), ובהתאם לבקשה להיתר בנייה מס' 20151158 שהוגשה על ידם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה (להלן: "**הבקשה להיתר**" או "**התוכנית**").
5. בהתאם לבקשה להיתר מתוכננות בבית, בין היתר, העבודות הבאות: חיזוק הבית, תוספת של 2.5 קומות ו- 5 דירות מגורים ובסך הכל 6.5 קומות כולל קומת עמודים ו-

11 דירות מגורים. בדירות הקיימות: סגירת מרפסות קיימות, הרחבת שטח דירות, ממ"דים וגזוזטראות. בדירות החדשות: ממ"דים, גזוזטראות, מרפסות גג ופרגולות. (עותק מהבקשה להיתר צורף לכתב התביעה).

6. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצלייה (להלן: "הוועדה" או "הוועדה המקומית") דנה בבקשה שהוגשה על ידי התובעים והחליטה בהחלטתה מיום 9.3.16. לאשר את הבקשה בתנאים (להלן: "החלטת הוועדה") (צורפה לכתב התביעה).

7. לטענת התובעים הם זכאים לאכוף על הנתבעים את ביצוע עבודות החיזוק בהתאם להוראות חוק החיזוק.

8. טענות הנתבעים יפורטו להלן בתמצית:

א. האישור העקרוני שהוציאה הוועדה המקומית מתנה את הבניה בהתאם לתכנית ברישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב לטובת הבית השכן ברחוב השושנים 8 (להלן: "רישום זיקת ההנאה"). אישור הוועדה האמור אינו עונה על הדרישה ל"אישור בתנאים" כמשמעותו בחוק החיזוק בהינתן כי עסקינן בתנאי קנייני ולא תכנוני. משכך אין בעניינו "החלטה" לאשר בקשה בתנאים" המהווה תנאי להגשת תביעה לפי חוק החיזוק, ודין התביעה להידחות על הסף מטעם זה;

ב. הנתבעים לא שותפו בהליכים לקראת חתימת ההסכם, מאחר וביקשו לקדם תכנית פינוי בינוי בבית, ואף לא זומנו לישיבות שנערכו עם היזם ו/או עם עו"ד שליווה את התובעים בהליך ההתקשרות החוזית עם היזם;

ג. הנתבעים לא ידעו כלל כי הוגשה בקשה להיתר; היזם ו/או בעלי הדירות לא המציאו לנתבעים הודעה על הגשת הבקשה להיתר, ואף לא הודיעו להם על כך בכל דרך אחרת, וזאת בניגוד לדרישות חוק התכנון והבניה, ובכך נמנע מהם להגיש התנגדות לתכנית;

ד. התנהלותם של התובעים בהליכי אישור התכנית והחתימה על ההסכם עם היזם נגועים בחוסר תום לב;

ה. תנאי למתן ההיתר הוא רישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב לטובת הבית השכן ברחוב השושנים 8. התובעים לא הציגו הסדר כלשהו בינם ובין הבניין השכן לעניין רישום זיקת ההנאה כנדרש ומשכך תכנית הבניה ממילא לא יכולה לצאת לפועל, כך שתביעה זו הוגשה טרם זמנה;

ו. רישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב לבניין השכן, מחייב גריעת שטח מהחלקה עליה בנוי הבית המשותף, וגריעה כאמור דורשת הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות בבית מושא ההליך ובבית השכן, וזו לא ניתנה;

ז. רישום זיקת ההנאה הנדרשת מהווה פגיעה קניינית ובלתי מידתית בזכויות הנתבעים בהינתן כי עסקינן בגריעה לצמיתות של זכות הבעלות של הנתבעים במקרקעין שלגביהם נדרש רישום זיקת ההנאה;

ח. קיימים פתרונות תכנוניים המאפשרים בינוי ומיצוי כל זכויות הבניה בתחומי החלקה בה בנוי הבית ללא רישומה של זיקת הנאה;

ט. אין בהסכם שנחתם בין התובעים ליזם סעיף בו התחייבו התובעים לאפשר קיומה של זיקת הנאה לטובת הבית הסמוך, ובתכנית ההדמיה בבקשה להיתר לא מצוינת כלל זיקת ההנאה כי אם רק בגוף הבקשה, כך שהתובעים לא היו מודעים לקיומה של זיקת ההנאה, ויש בכך כדי להעיד על חוסר תום ליבו של היזם.

י. ביצוע הפרויקט יביא לפגיעה באיכות חייהם של הנתבעים נוכח האבק, הכללוד והרעש שיגרמו כתוצאה מהבניה;

יא. ילדי הנתבעים סובלים מבעיות רפואיות ולא יוכלו לשהות כלל בבית בזמן הבניה. משכך, יאלצו הנתבעים לעזוב את דירתם למשך כל תקופת הבניה ולשאת בעלויות הגבוהות למציאת דיור חלופי;

יב. בהתאם לתכנית ממוקם הממ"ד בחלקה האחורי של הדירה, ופועל יוצא מכך הוא סגירה של שני חלונות קיימים. האחד, בחדר הילדים והשני בחדר שינה הורים. תכנון זה גורם לפגיעה בכניסת אור ואוויר לדירה והפסד של כיווני אוויר;

יג. בהתאם לתכנית יוארך המסדרון הקיים, בדירתם של הנתבעים, בשלושה מטרים נוספים, כך שייווצר מסדרון אפולולי וחשוך בתוך הדירה באורך של כ- 9 מ' וברוחב שאינו תקני, וכן יוקטן שטח חדר הילדים ל- 8 מ', וזאת חלף החדר הגדול שהיה.

יד. התכנית תיפגע בהנאה שמפיקים הנתבעים מדירתם, לא כל שכן לאחר שזו שופצה ועוצבה בסכומי כסף ניכרים;

טו. התכנית משנה את אופי הבניין הקיים, ואינה עולה בקנה אחד עם האופי המיוחד של האזור;

טז. ערבות הבדק אותה מעמיד היזם בהתאם להסכם בסך של 50,000 ₪ אינה מהווה בטוחה ראויה למכלול ההתחייבויות של היזם;

יז. התנהלותם של התובעים והיזם נגועה בחוסר תום לב ופוגעת בשוויון, והנתבעים אינם יודעים מה התמורה האמיתית אותה מקבלים התובעים. לפיכך, קיים יסוד להאמין שחלק מהתובעים קיבלו תמורה נוספת מהיזם;

יח. באמצעי התקשורת פורסם כי היזם והעומד בראשונה, מואשמים במעורבות בפרשת שחיתות בעיריית אשדוד וכי הוגש נגדם כתב אישום בעבירות של מתן שוחד והלבנת הון. כן תלויים ועומדים כנגד היזם מספר הליכים אזרחיים. עובדות אלו מעלות חשש כבד לגבי איתנותו של היזם ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להסכם שחתם עם התובעים;

יט. חלק מבעלי הדירות קיבלו מהיזם התחייבות לתשלום דמי שכירות, ומשכך קיימת פגיעה בשוויון בין הנתבעים לבעלי דירות אלה.

9. בתיק הוגשו ראיות, נשמעו עדויות וכן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

10. במסגרת הערכות כוללת של מדינת ישראל לרעידות אדמה, התקבלה בשנת 2005 החלטת ממשלה המאשרת את תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - תמ"א 38.

11. התכנית מעודדת ביצוע חיזוק בתים משותפים שהיתר להקמתם ניתן לפני 1.1.1980, וזאת מתוך הנחה כי התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413) אשר אושר לראשונה בשנת 1975 החל להיות מיושם רק מס' שנים לאחר המועד הנ"ל. העידוד מתבטא, בין היתר, בהענקת זכויות בניה ותמריצים נוספים למי שיפעלו לחיזוק המבנים שבבעלותם.

12. ביום 24.1.08 פורסם חוק החיזוק המהווה חקיקה משלימה לתמ"א 38, ונועד להקל על יישומה. מטרתו, כנלמד מדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), (הוראת שעה), התשס"ז - 2007, היא "להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף..... בכך מבקשת הצעת החוק ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת תכנית החיזוק, תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה".

13. חוק החיזוק קבע כללים משפטיים פרטניים לביצוע עבודות ברכוש המשותף לפי תמ"א 38, ובין אלו נכללו עבודות שמטרתן שינוי ברכוש המשותף (סעיף 3 לחוק החיזוק),

עבודות שמטרתן הרחבת דירה (סעיף 4 לחוק החיזוק), עבודות שמטרתן בניית דירה חדשה (סעיף 5 לחוק החיזוק) ועבודות שמטרתן הריסת בית קיים והקמתו מחדש (סעיף 5א לחוק החיזוק). החוק יצר מנגנון לפיו למפקח על רישום מקרקעין הסמכות ליתן הסכמה לביצוע העבודות חרף סירוב חלק מבין בעלי הדירות.

14. בע"א (חי') 899-03-09 קלצ'וק נ' אורון (פורסם בנבו), הדן בחוק החיזוק, אימץ כב' השופט כהן את גישת כב' השופט חשין בפסק הדין ברע"א 7112/92, צודלר נ' שרת, פ"ד מח(5) 550 באשר לתפיסת הקניין בבית משותף, וקובע כי ביישום חוק החיזוק יש צורך להפעיל הגנות שונות מאלה הנהוגות על פי התפיסה הכללית בדיני הקניין, ובמקום הגנה קניינית המאפשרת למיעוט למנוע את ביצוע העבודות, יש צורך להפעיל את "הגנת החבות" בלבד, דהיינו סעד שיותר בידיו פיצויים אם לאחר ביצוע פעולות החיזוק יתברר שנגרם לו נזק.

15. כב' השופט כהן אימץ בפסק הדין בעניין קלצ'וק את מבחני סבירות קבלת ההחלטה הנכפית על המיעוט גם בהקשר לחוק החיזוק: "ייתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון, והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם 'הפיחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. מעל לכל, אם ימצא המפקח מקום לכך, יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי. המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות מעין אלה תדללנה ויגרמו 'פיחותים', אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר".

ובהמשך: "אם יפעל היזם בשוויון בין בעלי הדירות בבית, ויפעל בתום לב, ויחשב את חישוביו לפי הנוסחאות הקבועות בסעיף 5 ל'חוק החיזוק', זכויות הקניין של המיעוט לא תוכלנה לגבור על הזכויות הקנייניות של הרוב, ולמפקח על רישום המקרקעין לא תהיה עילה לדחות בקשתו של הרוב לכפות על המיעוט את ביצוע עבודות החיזוק ובניית הדירות הנוספות לשלם מימון עבודות החיזוק, חרף הפגיעה הנגרמת".

16. סעיף 5 לחוק החיזוק, שכותרתו "עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה", והוא שעומד בלב המחלוקת בענייננו, קובע כדלקמן:

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודות ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה, כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן".

17. נבחן להלן את טענות הצדדים בהתאם לחקיקה והפסיקה הנ"ל

האם מתקיימים תנאי הסף להגשת התביעה

18. סעיף 2 לחוק החיזוק מורה כדלקמן: "(א) ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או

החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה. (ב) הוראות לפי חוק המקרקעין ימשיכו לחול על עבודה ברכוש המשותף, ככל שאינן סותרות את ההוראות לפי חוק זה.”

”היתר בניה” מוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: “היתר לפי חוק התכנון והבנייה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים”.

”החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים” מוגדרת בסעיף 1 לחוק החיזוק כדלקמן: “החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים, שהתקבלה במוסד תכנון, לאחר שהתקיימו כל אלה: 1. מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה התשכ”ה - 1965 (להלן: “חוק התכנון והבנייה”) ככל שנקבעו; 2. מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה; 3. הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה - מוסד התכנון החליט בהן;

19. הוועדה המקומית אישרה בהחלטה מיום 9.3.16 כי כל התנאים המפורטים בסעיף 1 לחוק החיזוק מולאו. משהתקבל אפוא, אישור הוועדה המקומית לקיומם של תנאים אלה, הרי שאנו נכנסים בגדרו של חוק החיזוק. העובדה כי הוועדה התנתה את מתן ההיתר בקיומם של תנאים נוספים כגון רישום זיקת הנאה, אינה מאיינת את קיומם של התנאים האמורים.

20. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת הנתבעים לדחיית התביעה על הסף.

רישום זיקת הנאה

21. בהתאם לתכנית מתוכננת להיבנות 5 דירות נוספות על 6 הדירות הקיימות ובסך הכל יהיו בבית 11 דירות.

22. בהתאם למכתבו של יועץ התנועה העירוני, מר ערן קרן, “עבור 11 יחידות דיור בכל חלקה נדרשים על פי התקן 13 מקומות חנייה” (צורף כנספח 1 לחוות דעתו של יועץ התנועה מטעם התובעים, מהנדס אזרחי, יזאן זועבי (להלן: “המהנדס זועבי”).

23. נוכח דרישה זו של הוועדה, כעולה מחוות דעתו של המהנדס זועבי, ועל מנת ליצור את מספר החניות הנדרש, מתוכננת בתכנית זיקת הנאה הדדית לבית, מושא ההליך ולבית הסמוך לו (רחוב שושנים 8) למעבר כלי רכב לשני הבתים האמורים (ראה סעיף 7 לחוות דעתו של המהנדס זועבי). דהיינו, כל חלקה מפרישה שטח לטובת זיקת הנאה למעבר כלי רכב לטובת החלקה הסמוכה ובשטח שנוצר מצירוף שטחים אלו נוצרת גישה לרכבים לשתי החלקות.

24. עוד עולה מחוות דעתו של המהנדס זועבי כי נשקלו “מספר חלופות לתכנון החניות בבניין, תוך התחשבות במגבלות הקיימות, לרבות: מבנה ומיקום הבניינים הקיימים, קווי המגרש, מדיניות הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצלייה, והשתלבות בבניין הקיים” (ראה סעיף 5 לחוות דעתו) ובסופו של יום מצא המהנדס זועבי כי “לא ניתן, במגבלות הקיימות, לתכנן את הפרויקט (עם מספר החניות הנדרש) באופן טוב יותר מהתכנון המוצע” (סעיף 7 לחוות דעתו) הכולל את זיקת ההנאה בין שני הבתים, כאמור.

25. בנסיבות אלה, התנתה הוועדה המקומית את מתן ההיתר “ברישום זיקת הנאה למעבר כלי רכב עם בניין השושנים 8” (ראה החלטת הוועדה מיום 9.3.16).

26. בחקירתו הנגדית הבהיר המהנדס זועבי כי בעוד שבבית שברחוב השושנים 8 ניתן היה לייצר 13 חניות ללא רישום זיקת הנאה לא ניתן היה לעשות כן ביחס לבית מושא ההליך: “ש. למיטב ידיעתך ולמיטב ניסיוןך המקצועי, ניתן לייצר פתרון חנייה ריאלי בשושנים 8 (הבית הסמוך, הוספה שלי א.ש.) ת. כן ש. ולגבי 6 (הבית מושא ההליך, הוספה שלי א.ש.) ת. אין פתרון ריאלי. הם חייבים את זיקת ההנאה. הם לא מגרשים זהים. ש. ב - 8 אפשר לייצר בלי זיקת הנאה וב - 6 אי אפשר לייצר בלי זיקת הנאה ת. נכון” (פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ’ 13, שורות 9-3).

ראיות ועדויות היו אמינים עלי, ולא נסתרו.

27. הנתבעים הציגו שרטוט בו מוצגת, לטענתם, חלופה המציעה את מספר החניות הנדרש בהתאם לדרישת הוועדה בלא צורך ברישומה של זיקת הנאה (צורף כנספח יח לתצהירו של הנתבע 2). בחקירתו הנגדית הסביר הנתבע 2 כי שרטוט זה נערך לאחר "התייעצות עם אדריכל", וכי המדובר ב – "אדריכל מוכר ידוע ויש המון פרויקטים בהרצלייה שהוא ביצע" (פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 14, שורה 20 וכן שורה 31). בהינתן כי השרטוט שהוצג לא הוגש ע"י עורכו, כלל לא ברורה זהותו, ובשים לב לעובדה שעורכו לא התייצב לעדות ולא נחקר עליו, לא מצאתי ליתן לשרטוט האמור כל משקל ראיתי.

28. יתירה מכך, בחקירתו הנגדית שלל המהנדס זועבי את התכנונה של החלופה שהוצעה בשרטוט הנתבעים לעיל, ראה פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 11, שורות 33-38: "ש. נכון שהיה אפשר למקם חניות 9 ו – 10 כמו שמיקמת יכולת למקם אותם כאן בצד האחורי של המגרש? ת. לדבר על זה ולהסביר את זה במלל זה מאד קל אבל זה לא נכון, שמונה מטר לא מספיק לחניית רכב ומעבר תקני מאחוריה. ש. אתה רצית לתכנן ככה שלא יהיה מעבר מסוים מסביב כל הבניין אלא רק צד וצד? ת. יש סיבה מאד מוצדקת לדבר כזה. אני רציתי לתכנן מצב שיכניס לי מקסימום חניות שיענה לי על הדרישה. המצב הזה שאת מבקשת מוריד ארבע חניות לפחות" (ראה גם עמ' 12, שורות 23-8).

29. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי רישום זיקת הנאה מחייב הסכמה מפורשת של הנתבעים בהינתן כי בהתאם לסעיף 5 (ב) לחוק החיזוק רשאי המפקח להתנות את ביצוע העבודות "בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין". מהוראת הסעיף עולה כי המפקח רשאי להתנות את ביצוע העבודות, בבית מושא ההליך, ברישום זיקת הנאה, אף ללא הסכמת הנתבעים, ובלבד שהתביעה הוגשה ברוב הדרוש לכך בהתאם לסעיף 5 לחוק החיזוק, כפי מקרה זה שלפני.

30. ויטעם, אמנם להגנה על הקניין מפני פגיעה יש לה מעמד חוקתי. יחד עם זאת בעלים של נכס ובכלל זה נכס מקרקעין, אינו נהנה מאוטונומיה מוחלטת בבואו להגן על החזקתו בנכס ואין לו זכות בלתי מסויגת "לשרירות בעלים". יתכנו מקרים שבהם מכוח עקרון תום הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי בעל זכות קניינית הגם שזו נפגעה (ראה סעיף 14 לחוק המקרקעין, וכן ע"א 8661/10, נעמה נ' טורקיה (פורסם במאגרים משפטיים)). אני מוצאת כי רישום זיקת הנאה במקרה דנן נמנה על המקרים האמורים נוכח האינטרס שבביצוע עבודות החיזוק בבית.

31. לא מצאתי כי יש צורך במסגרת ההליך הנוכחי לבחון את שאלת הסכמת בעלי הדירות בבית הסמוך (רחוב השושנים 8) לרישום זיקת ההנאה בהינתן כי הם אינם צד בהליך שלפני, ובהינתן כי כל שנדרש במסגרת הליך זה הוא לבחון האם קבלת פתרון החניה שמוצע בתכנית באמצעות רישום זיקת הנאה הדדית בין שני הבתים מהווה פגיעה קניינית בזכויות הנתבעים, כנטען על ידם אם לאו. בחינה כאמור נעשתה, ולא מצאתי כל פגיעה קניינית המצדיקה את אי ביצוע העבודות. ברי כי רישום זיקת ההנאה בפועל מותנה בעמידה בנהלי המרשם.

32. מצאתי לשלול את טענת הנתבעים כי בהסכם שנחתם בין התובעים ליזם לא קיים סעיף בו התחייבו התובעים לאפשר קיומה של זיקת הנאה לטובת הבית הסמוך, נוכח האמור בסעיף 24.7 להסכם (צורף כנספח 1 לתצהירו של התובע 6) המאפשר רישום זיקת הנאה לבית מושא ההליך ולזה הסמוך לו. אמנם בסעיף האמור מזוהה הבית הסמוך כחלקה 138 ברחוב השושנים 6 בעוד שהמדובר בבית המזוהה כחלקה 139 ברחוב השושנים 8, ואולם מצאתי לקבל בעניין זה את עדותו של עו"ד שפירא, שייצג את התובעים במשא ומתן מול היזם ואשר הוזמן לעדות מטעם הנתבעים, כי עסקינן בטעות סופר (ראה עדותו של עו"ד שפירא פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 3, שורות 2-3).

33. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי העובדה שבתכנית ההדמיה לא צוינה זיקת ההנאה מעידה על הסתרה וחוסר תום לב מצד היזם, וזאת בשים לב לעובדה שזיקת ההנאה צוינה בתכנית עצמה ואפשרות קיומה עוגנה בהסכם שנחתם בין התובעים ליזם (ראה כאמור סעיף 24.7 להסכם).

34. נוכח האמור לעיל, ובהינתן כי תנאי להיתר הוא רישום זיקת ההנאה ובהינתן כי לא מצאתי כי יש ברישום האמור פגיעה קניינית בזכויות הנתבעים המצדיקה את אי ביצוע העבודות, מצאתי לדחות את טענת הנתבעים בעניין זה.

טענות הנתבעים לפגיעה תכנונית

35. בהתאם לתכנית נסגרים שני חלונות קיימים בשני חדרי שינה. האחד, חלון הפונה לכיוון צפון. והשני, חלון הפונה לכיוון צפון מזרחי. סגירת חלונות אלה נדרשה, כעולה מחוות דעתו של האדריכל דרור רימוק (להלן: "האדריכל רימוק") שהוגשה מטעם התובעים, לצורך בניית ממ"ד בדירת הנתבעים, הנדרש, בין היתר, לצורך חיזוק מבנה הבית מפני רעידות אדמה (סעיף 8 ו-9 לחוות דעתו של האדריכל רימוק).

36. יחד עם זאת, וכעולה מהתכנית ומחוות דעתו של האדריכל רימוק, מתוכננים בחדרים אלה חלונות רחבים וגדולים המאפשרים כניסת אור וזרימה של אוויר לחדרים האמורים (ראה סעיף 8 לחוות דעתו של האדריכל רימוק). טענות הנתבעים לפגיעה בכניסת אור ואוויר לדירתם כתוצאה ממיקומם של חלונות אלה חלף החלונות שנסגרו, נטענו בעלמא, ולא הוכחו.

37. הנתבעים הציגו שרטוט נוסף, בו מוצגת, לטענתם, חלופה למיקום שונה של הממ"ד (בחזית הבית) (נספח כב' לתצהירו של הנתבע 2), ואולם גם שרטוט זה לא הוגש ע"י עורכו, וכלל לא ברורה זהותו. בנוסף, לא הוכחה היתכנות המודגם בתשריט והתאמתו לחוקי התכנון והבניה. משכך, ובשים לב לעובדה שעורכו לא התייצב לעדות, ולא נחקר עליו, לא מצאתי ליתן לשרטוט האמור כל משקל ראיתי.

38. יתירה מכך, בחקירתו הנגדית של האדריכל רימוק את היתכנותה של החלופה שהוצעה בשרטוט האמור, ראה פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 9, שורות 37-46: "ש. נשאלת גם בעניין אפשרות של מיקום הממ"ד בחזית, במסגרת האלטרנטיבות שבחרתם אם היה ניתן למקם בחזית, להערכתך, עד כמה זה היה פוגע במרפסת שאפשר להוסיף? ת. זה היה פוגע בהרבה דברים לא רק במרפסת. א' המרפסת הייתה קטנה בצורה משמעותית כרגע יושבת על כל החזית. ב' הממ"ד לא היה בצורה של מלבן אלא בצורה של ר'. ג'. זה היה פוגע בכניסה לחנייה. ד' בגלל שיש חלון על הקיר המזרחי אז היה צריך לעשות שם דלת הדף מוגברת או קיר מגן שהיה פוגע בחלל ודבר אחרון שאם רוצים להשתמש בזה בתור חדר שינה והוא ממוקם בפינה האלכסונית לבית זה מאד לא פרטי. ש. במסגרת התיאור הדמיוני של חברתי למקם את הממ"ד בצד של הבניין אני מבין שבמקרה כזה היה נותר חדר ללא חלון וללא אוורור. ת. נכון. או ללא חלון או ללא אפשרות לפצל את החללים בצורה פרטית".

39. טענת הנתבעים כי בהתאם לתכנית יוארך המסדרון הקיים בדירתם, כך שיווצר מסדרון אפולולי וחשוך בתוך הדירה, לא הוכחה. כך גם לא הוכחה טענת הנתבעים כי חדר הילדים יוקטן. נהפוך הוא, בהתאם לתכנית מתווסף לדירה ממ"ד שהכניסה אליו היא מתוך חדר השינה הצמוד לו. לנתבעים ניתנה אפשרות גישה עצמאית לממ"ד ע"י הארכת המסדרון והקטנת חדר השינה, ואולם עסקינן באפשרות לבחירתם של הנתבעים. ראה עדותו של האדריכל רימוק, פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 8, שורות 13-16: "כרגע הממ"ד נכנס מתוך חדר. אם עושים פרוזדור זה משתנה. הרעיון של למקם את הממ"ד פה היה לייצר פה אפשרות לפרוזדור ואז להפריד את הממ"ד מחדר השינה. הפרוזדור זה שינוי פנימי יש כאלה שירצו לעשות ויש כאלה שלא. זאת אומרת שאם הנתבעים ירצו יהיה אפשר ליצור את הפרוזדור הזה". מכל מקום, לדידי, אי שביעות רצונם של הנתבעים מהתכנון הפנימי של דירתם, על אף שניתנו להם מספר חלופות, נסוג מפני חשיבות חיזוקו של הבית מפני רעידות אדמה.

פגיעה בשוויון

40. מעדותו של התובע 6 עולה כי שניים מבעלי הדירות בבית ה"ה סולניק וביטר (תובעים 4, 5 ו-8), קיבלו מהיזם התחייבות להשלמת דמי שכירות שיקבלו במשך תקופת הבניה לעומת דמי השכירות שהיו מתקבלים בהתאם לערכה של דירתם אלמלא ביצוע העבודות (ראה פרוטוקול מיום 28.9.17, עמ' 8, שורה 21, וכן שורות 31-32). תימוכין

לכך מצאתי בעדותו של עו"ד שפירא (ראה פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 2, שורות 12-13).

41. עוד עולה מהעדויות שהובאו בפני כי ההצעה להשלמת דמי השכירות, כאמור, נעשתה בשקיפות, הוצעה לכל בעלי הדירות בבית, לרבות הנתבעים, והם בחרו שלא לקבלה.

ראה עדותו של עו"ד שפירא, פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 2, שורות 12-13. ראה עדותו של התובע 6, פרוטוקול מיום 28.9.17, עמ' 8, שורות 21-24, , וכן עמ' 9, שורות 22-24. ראה עדותו של התובע 8, פרוטוקול מיום 28.9.17, עמ' 12, שורה 46 ועמ' 13 שורה 1. ראה עדותו של הנתבע 2, פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 13, שורות 36-44. עדויות אלה היו אמינות עלי, ולא נסתרו.

42. בנסיבות אלה בהן התמורה להשלמת דמי השכירות הוצעה לכל בעלי הדירות בבית, ובכלל זה הנתבעים, לא מצאתי כי הופר השוויון.

טענות נוספות

43. טענת הנתבעים כי כלל לא שותפו בהליכים לביצוע הפרויקט והחתימה על הסכם לביצוע העבודות עם היזם נסתרו בחקירתו הנגדית של הנתבע 2, ושוכנעתי כי הנתבעים ידעו היטב על המהלכים שבוצעו לצורך קידום עבודות החיזוק (ראה פרוטוקול מיום 24.12.17, עמ' 13, עמ' 21-44).

44. טענת הנתבעים כי נמנעה מהם הזכות להגיש התנגדות לתכנית, היא טענה במישור התכנוני, שאין למפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון בהן, ועל הנתבעים להפנות טענותיהם אלה בפני הטריבונל המוסמך.

45. טענות הנתבעים כי ילדיהם סובלים מבעיות רפואיות נטענו בעלמא ולא הוכחו.

46. לא נטען וממילא לא הוכח הכיצד יש בכתבי האישום שהוגשו כנגד היזם כדי להעיד על העדר התכנתו הכלכלית. ברי כי פרסומים בעיתונות, עליהם נסמכים הנתבעים, אינם מהווים ראיה לכך, והעובדה שהוגש כתב אישום, אין בה כשלעצמה, כדי להעיד על קושי כלכלי כזה או אחר. היה על הנתבעים להצביע על קושי כלכלי ממשי, ולהוכיחו - דבר שלא עלה בידיהם. משכך לא מצאתי לקבל את טענותיהם בעניין זה.

הנתבעים צרפו לתצהירו של הנתבע 2 מסמך בו מפורטים מספר הליכים משפטיים אזרחיים לצד שמו של היזם (נספח יג'). ואולם, לא ניתן כל פירוט באילו הליכים המדובר, האם וכיצד הם רלבנטיים לענייננו, מהו סטטוס הטיפול בהם, תוצאותיהם, והכיצד יש בהם כדי להעיד על העדר התכנתו הכלכלית של היזם. משכך, לא מצאתי לקבל את טענות הנתבעים אף בהקשר זה.

47. טענת הנתבעים לפיה גובה ערבות הבדק אותה העמיד היזם נמוך נטענה בעלמא ולא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בה. משכך מצאתי לדחות טענה זו.

48. הנתבעים טענו בסיכומיהם כי מאחר וחוות דעת המומחים שהוגשו מטעם התובעים בתיק הם של יועץ התנועה והאדריכל שהיו מעורבים בהכנת התכנית, אין המדובר בחוות דעת מומחים כי אם בעדות של "עד מטעם" שמסקלה הראייתית אפסי. לא אוכל לקבל עמדה זו. הכלל הקבוע בסעיף 2 לפקודת הראיות מורה "הכל כשרים להעיד בכל משפט", ובמצב דברים זה אין "בנגיעה אישית" של העד בעניין הנדון בבית המשפט, כדי לפגוע בכשרותו להעיד, ויכולה להיות לכך השלכה, אך ורק לעניין משקלה הראייתית של עדותו (ראה י. קדמי, על הראיות, חלק ראשון, 2009, עמ' 527). בהינתן כי לא הוגשו חוות דעת מטעם הנתבעים, ובהינתן כי האמור בחוות דעת אלה לא נסתר בחקירותיהם הנגדיות של הנ"ל, מצאתי לקבל את האמור בהם.

49. ברי כי ביצוע העבודות יגרום בהכרח לאבק, לרעש וללכלוך, כנטען על ידי הנתבעים. ואולם, האינטרס שבביצוע עבודות החיזוק בבית נסוג, לדידי, מאי הנוחות הזמנית שתגרם לבעלי הדירות, ובכלל זה לנתבעים במהלך ביצוע העבודות. הוא הדין ביחס לטענת הנתבעים באשר לשינוי אופי הבית כתוצאה מביצוע העבודות.

50. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומאשרת לתובעים, חרף התנגדותם של הנתבעים, לבצע את העבודות, מושא התביעה בהתאם לחוק החיזוק, ולשם כך אני ממנה את עו"ד גיא בטאט ו/או עו"ד שפירא להתקשר ולחתום בשם הנתבעים לשם ביצוע העבודות, על הסכמים עם היזם, עם רכשי הדירות החדשות, על הבקשות לתיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק, לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רכשי הדירות החדשות, לרישום משכנתאות ו/או שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לרבות רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח, וכן על המסמכים הדרושים לרישום זיקת הנאה הדדית ביחס למקרקעין הידועים כגוש 6529 חלקה 138 ברחוב השושנים, 6 הרצלייה ובחלקה 139 ברחוב השושנים, 8, הרצלייה.

51. לנתבעים שמורה הזכות לקבל מהיזם השלמת דמי השכירות בין דמי השכירות שיקבלו בפועל בעבור השכרת דירתם, ככל שיבחרו להשכירה במהלך ביצוע עבודות החיזוק, לבין דמי שכירות אשר יכולים להתקבל עבור דירה דומה, בכפוף לכך שתשלח על ידם הודעה על כך לב"כ התובעים בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק דין זה (ימי הפגרה יבואו במניין הימים). במקרה שיבחרו הנתבעים להשכיר את דירתם יחולו עליהם אותם תנאים שניתנו לתובעים 4-5 ו - 8.

52. כן אני מורה לנתבעים לשלם לתובעים הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עו"ד בסך של 8,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכת, בהעדר הצדדים, היום, יא' באב תשע"ח, 23 ביולי, 2018.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה